

Attribution du Profit aux Établissements Stables

Retour sur la fin de l'exception française

FORVIS MAZARS — AVIS D'EXPERTS | JANVIER 2025

Attribution du Profit aux Etablissements stables

Tags

Technical publication

Janvier 2025 | Retour sur la fin de l'exception française

Dix ans après l'arrêt Hypo , quatre ans après l'arrêt Conversant , cet article se propose de faire un retour sur l'applicabilité de « l'Approche Autorisée de l'OCDE » ou « AoA » en France, quant à l'attribution du profit aux établissements stables (« ES »). Ce sujet est clé, notamment pour les Etablissements Financiers, qui utilisent fréquemment des succursales pour structurer leurs opérations.

On rappelle que l'AoA a fait l'objet d'un développement approfondi dans le rapport de 2008 sur l'attribution de bénéfices aux établissements stables (le « Rapport de 2008 ») , lui-même complété par une seconde version, en 2010 . La question qui s'est longtemps posée a été celle de la reconnaissance de l'AoA en droit français avant l'entrée en vigueur des nouvelles conventions fiscales intégrant explicitement l'article 7 révisé de l'OCDE et l'arrêt Hypo

1.1. L'Approche Autorisée de l'OCDE

L'AoA, repose sur le principe selon lequel, pour déterminer le profit attribuable à un ES, celui-ci doit être considéré comme une entité distincte et indépendante. Partant, deux étapes doivent être mises en œuvre :

Etape 1 : Détermination des fonctions, des risques et des actifs attribuables à l'ES[1] ; puis,

Etape 2 : Détermination du profit attribuable à l'ES, dans des conditions de pleine concurrence.

Depuis 2008, l'AoA s'est ainsi largement imposée, dans la plupart des juridictions de l'OCDE.

1.2. L'Arrêt Hypo et la Pratique Française

En France, beaucoup de praticiens se sont fondés sur l'arrêt Hypo pour l'attribution de capital aux établissements stables, arrêt décrit ci-dessous, de manière simplifiée :

Les faits[2]

§ La société Bayerische Hypo und Vereinsbank AG (HVB-AG), une banque allemande, a créé une succursale en France sous le nom de « HVB-AG Paris ».

§ HBV-AG a injecté dix millions de deutsche marks de capital à sa succursale française, mais l'administration fiscale française a considéré que ce capital était insuffisant au regard de ce qu'une entité indépendante exerçant une activité comparable aurait dû avoir si elle avait été une entité juridiquement indépendante.

§ En conséquence, l'administration a refusé la déduction des intérêts sur la partie jugée excessive des emprunts.

§ L'administration s'est, notamment, fondée sur la convention fiscale franco-allemande en vigueur au moment de l'exercice redressé (1994), c'est-à-dire en sa version du 21 juillet 1959.

§ Elle s'est également fondée, sur ce point, sur les commentaires de l'OCDE sur l'article 7 de la convention-modèle du 22 juillet 2010, qui faisaient référence à l'AoA, l'AoA seule permettant, ici, de fonder un redressement sur la base d'un capital notionnel différent du capital comptable de la succursale.

La décision⁸

§ Selon le Conseil d'Etat, pour interpréter la convention il n'est pas possible de se référer aux commentaires de l'OCDE qui sont postérieurs à l'adoption des stipulations en question.

§ Il n'était donc pas possible de mettre en œuvre l'AoA ni de se référer à un capital notionnel.

En précisif également, de l'arrêt Conversant.

3.1. Les nouvelles conventions et l'adoption de l'Instrument Multilatéral

Depuis l'adoption de l'Instrument multilatéral^[3] (« MLI ») par l'OCDE en 2017 et son entrée en vigueur en France au 1er janvier 2019, un certain nombre de conventions fiscales ont été mises à jour, avec typiquement l'inclusion d'une référence à l'AoA. Selon les données disponibles, le MLI a modifié plus de 1 500 conventions fiscales à travers le monde^[4]. Par ailleurs,

d'autres conventions ont été mises à jour entre la date de publication du Rapport de 2008 (Juillet 2008) et celle du MLI (Juillet 2019), avec, potentiellement, également une référence à l'AoA. Une analyse du réseau conventionnel français de ce point de vue est indiquée ci-dessous :

Ainsi, il apparaît qu'un nombre important – quoique minoritaire - des conventions de la France ont été modifiées depuis la date de publication du Rapport de 2008, avec potentiellement, une référence à l'AoA.

3.2. L'affaire Conversant (Valueclick)

[Résumé de l'affaire Conversant/Valueclick :] Valueclick France fournissait à la société irlandaise des services d'assistance marketing y compris la préparation conséquente des accords contractuels.

§ Sur cette base, l'administration a estimé que l'activité de Valueclick France incluait le « pouvoir de conclure des contrats » et partant, entraînait la création d'un établissement stable en tant qu'agent dépendant de Valueclick International Ltd en France.

§ La Société faisait valoir cependant que :

§ Les commandes étaient validées par Valueclick International Ltd et que,

§ Quand bien même cette validation était formelle, celle-ci prémunissait la reconnaissance d'un établissement stable au vu des dispositions de la convention fiscale franco-irlandaise de 1968 alors en vigueur.

La décision⁸

§ Le Conseil d'État a notamment pris en compte les commentaires de l'OCDE, publiés respectivement le 28 janvier 2003 et le 15 juillet 2005, postérieurs donc, à la date de la convention.

§ Or ces commentaires indiquent qu'une validation formelle au niveau de l'application de l'AOA et plus largement des principes OCDE, même dans le contexte de transactions couvertes par des conventions fiscales anciennes.

Par Jérôme Labrousse, Associé et Guillaume Madelpuech, Directeur / Forvis Mazars Avocats

[1] Le capital libre attribuable à l'ES est notamment clé pour les établissements financiers (Banque, Assurance, Gestion d'Actifs), pour lesquels une méthode économique reposant sur la considération du retour sur le capital libre est souvent utilisée.

[2] Présentation simplifiée

[3] Le MLI a été conçu pour mettre en œuvre rapidement les mesures relatives aux conventions fiscales issues du projet BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) de l'OCDE et du G20, sans avoir à renégocier chaque convention bilatérale individuellement

[4] Bulletin for International Taxation, December 2022, Assessing the Impact of the OECD's Multilateral Instrument on China's Tax Treaties (2017-2022), IBFD

Par Jérôme Labrousse, Avocat, Associé fiscaliste - Paris